法学研究 Chinese Journal of Law
Vol.47，No.1（2025）

·中国自主法学知识体系构建·

法秩序统一性原理之建构

雷　磊 *

内容提要：法秩序是基于实在法的法学构造物，它预设了应然的和动态的视角。法秩序由法律体系、得到制定法认可的其他一般规范，以及依据一般规范产生的个别规范构成，是以制定法为主体的多元规范体系。法秩序的统一性既是法律科学追求的理想，又是司法裁判的辅助性原则。法秩序统一性的认识论要求包括两个方面：一是法秩序的效力统一性，这既包括空间面向上法的阶层构造与效力统合，又包括时间面向上法的连续性与稳定性；二是法秩序的价值统一性，这包括空间面向上部门法间的价值协调和时间面向上的同案同判。法秩序的效力统一性和价值统一性应在宪法层面实现耦合。法秩序统一性的方法论构造体现为规范意义的体系化塑造、规范要求的一致化建构，以及规范体系的完备化发展。法秩序统一性的“价值基点”在于法的安定性和形式正义，它是法秩序必要而非充分的构成条件，是相对的而非绝对的理想原则。

关键词：法秩序　法律体系　法律适用　同案同判　法制统一

引　言

在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家的进程中，“法制统一”和“统一法律适用”始终是关键问题。法制统一和统一法律适用的实现，既有赖于制度设计与责任压实，也有赖于理论支撑。就后一方面而言，学界近年来围绕“违法判断的法域协调”问题展开的讨论最为典型。在这场主要爆发在刑法学界的讨论中，争议的核心问题在于“是否存在统一的（一般）违法性概念”或“部门法违法性是否可以作独立判断”。〔1〕无论持何种立场，争论者无一例外地诉诸法秩序统一性原理寻求理论支撑，分歧只在于对这一原理之内涵和要求的具

* 中国政法大学钱端升讲座教授。
本文系2020年度北京市社科基金重大项目“数据科技时代法学基本范畴的体系重构”（20ZDA02）的阶段性成果。

〔1〕这场争论中的对立立场为“违法一元论”与“违法多元论”。前者包括“严格的违法一元论”（参见时延安：《论刑事违法性判断与民事不法判断的关系》，《法学杂志》2010年第1期，第93页以下）和“缓和的违法一元论”（参见周光权：《法秩序统一性原理的实践展开》，《法治社会》2021年第4期，第1页以下），后者近来又发展出“缓和的违法多元论”（参见张峰铭：《法秩序在何种意义上是统一的——对部门法交叉问题的前提性反思》，《东岳论丛》2022年第4期，第168页以下）。

中国知网 https://www.cnki.net

体理解。〔2〕

法秩序统一性原理构成法制统一和统一法律适用的法理基础。对于法秩序统一性原理的阐释，需要超越特定部门法而回归法理论层面。在欧洲大陆，随着19世纪以实在法之体系化为核心的法律科学思潮的兴起，法秩序统一性原理逐渐成为法教义学研究的核心，诸多学派和学者从不同视角论证过这一观念。1935年，德国法学家卡尔·恩吉施首次从法理论视角出发明确提出法秩序统一性原理，并揭示了其对法教义学解释与建构作业的核心意义。自此以后，无论在立法、执法还是司法活动中，法秩序统一性原理都扮演着非常重要的角色，可谓“法理论、民法和国家法学的论证公式”。〔3〕简单地说，法秩序的统一性指特定目标下法秩序各部分之间相互关联为整体的状态。但是，“特定目标”指的是什么？“法秩序的各部分”如何划分？“相互关联”又有哪些具体表现？这些问题尚待理论解答。目前我国法理学界关于法秩序统一性原理的研究刚刚起步，讨论也较为零散，仅集中于部门法之间及部门法与整体法秩序间的关系，〔4〕以及法秩序内部（法律规范之间）无矛盾这两个主题。〔5〕有鉴于此，本文拟在新的时代背景下对法秩序统一性原理进行体系化建构，旨在从认识论要求和方法论构造两个层面进行全景式鸟瞰，推动法秩序统一性原理相关研究的深入。

一、法秩序的视角与构成

“秩序”与“统一性”是相互蕴含的两个概念。对于“法秩序”的理解直接影响法秩序统一性的内涵与要求，要对法秩序统一性原理进行体系化建构，有必要先行澄清“法秩序”的视角和构成。

（一）法秩序的视角

法秩序是否等同于实在法（甚或制定法）的统一体或体系？卡纳里斯曾区分体系的两种类型，一种是认识的体系，一种是认识对象的体系。〔6〕就法律领域而言，所谓认识对象的体系是指实在法本身的体系（也可称为“法制”），即主要由立法者所创设的一套客观存在的具有统一性的法律现象的整体。认识的体系是对法律现象进行学术建构或加工后的产物。不同体系观对于两类体系间关系的判断并不相同：激进的体系观只承认体系是科学认知的产物，认为根本不存在固有意义上的对象体系；温和的体系观则认为，认识的体系与对象的体系之间存在紧密关联，认识的体系必须基于和忠于既有的对象体系来进行认识论加工。诚如科殷所言，“统一的法律构造并不必然意味着统一的立法。当然，统一的立法是统一的法律构造最重要的形式”。〔7〕在欧陆法律史上，共同法就是一种在继受罗马法的基础上发展起来的欧陆近代私

〔2〕“严格的违法一元论”预设了法秩序的规范统一（存在论统一），“违法多元论”预设了法秩序的价值统一（目的论统一），“缓和的违法一元论”预设了兼顾存在论统一和目的论统一的混合式理解。

〔3〕Vgl. Manfred Baldus, Die Einheit der Rechtsordnung: Bedeutungen einer juristischen Formel in Rechtstheorie, Zivil- und Staatsrechtswissenschaft des 19. und 20. Jahrhunderts, Berlin: Duncker & Humblot, 1995, S. 162-177.

〔4〕参见前引〔1〕，张峰铭文，第168页以下。这一关系的特定面向即为“违法类型”冲突的排除，对此参见陈金钊、吴冬兴：《论法秩序统一性视角下违法判断的法域协调》，《东岳论丛》2021年第8期，第162页以下。

〔5〕参见吴冬兴：《论法秩序统一性原则的司法应用逻辑》，《法学》2022年第7期，第29页以下。

〔6〕参见［德］克劳斯-威廉·卡纳里斯：《法学中的体系思维与体系概念：以德国私法为例》，陈大创译，北京大学出版社2024年版，第5页。

〔7〕Helmut Coing, Die europäische Privatrechtsgeschichte der neueren Zeit als einheitsliches Forschungsgebiet, 1 Ius commune 4 (1967).

中国知网 https://www.cnki.net

法的统一基础，它由概念、原则、思维传统和规则组成，并在欧洲大陆各个大学被教授，在各地的法律实践中被运用。法秩序就预设了这样一种温和的体系观，它是基于实在法的法学构造物，是对象和方法的混合。法秩序不是纯空想之物，不能脱离实在法基础，实在法为法秩序提供了经验材料和认知对象；仅有实在法也不足以构成法秩序，法秩序是法学上对于以制定法为主的规范性材料进行体系化加工后的产物。作为法学构造物，法秩序预设了如下特定的视角。

1. 法秩序预设了应然的而非实然的视角

实然视角下的法秩序，指的是通过法的实施和法的实现而建立起的人与人之间的一种有条不紊的状态。〔8〕这种状态是根据法律规范建立的社会关系状态（法律关系状态），是存在于法律主体之间且符合法律规定及其价值取向的事实上的权利义务秩序。彼得拉日茨基就认为，社会主义法秩序的实质要素是：其一，社会群体中所有能够工作的成员负有一种义务，即为了群体的共同善而工作，积极参与对于维系群体以及满足它的其他需求具有必要性的物质利益的集体生产。其二，每一个群体成员享有这样的权利，即从使用集体拥有的生产资料集体地生产出来的东西的总储备中，得到维持其生存和满足他的其他需求所需的东西。〔9〕实然视角下的法秩序指涉与法的运行相关的社会现实，更多属于社会学的范畴。与此不同，应然视角下的法秩序指涉的是作为规范性事物的法本身，属于法学的范畴。在此视角下，法秩序由应然状况或应然语句组成。〔10〕它本身只是为现实世界提供或规定了一个理想的法律世界范本，即应然状态下人与人之间的权利义务关系。这一概念本身并不包含这种理想范本在社会现实中的落实，既不涉及法的实施，也不涉及法的实现。换言之，法秩序的统一性在现实中永远不可能完全实现，它本身并不属于经验世界，只能作为理念或者原则而存在。但是，法秩序的统一性要求以恰当方式连接所有的法律规范以及与法律相关的规范，在认识论层面形成统一判断，这构成了法（教义）学研究的前提。因此，法秩序是应然秩序而非实然秩序。法秩序的统一性是应然法律世界在效力和价值上的统一，而非社会现实中事实状态的统一。

2. 法秩序预设了动态的而非静态的视角

秩序既可以是静态的，也可以是动态的。这种静态性或动态性既可以体现在空间面向上，也可以体现在时间面向上。就空间面向而言，在静态秩序中，规范因其内容而有效。众多规范的效力可以追溯至这样一个基础规范——它的内容可以涵摄构成这一秩序之众多规范的内容，两者是一般涵摄特殊的关系。静态秩序的典型是道德秩序。在动态秩序中，规范因被授权而有效。被预设的基础规范仅仅包含着对创设规范之构成要件的设定，规定了基于这一基础规范之秩序的众多规范应当如何被创设，而不规定或主要不规定这些规范的内容。〔11〕动态秩序的典型就是法秩序。例如，立法机关因获得宪法规范的授权而创设一般法律规范，一般法律规范的效力来自于宪法规范；司法机关因获得一般法律规范的授权而创设个别法律规范（司法裁判），司法裁判的效力来自于一般法律规范。就时间面向而言，静态秩序呈现出超时限的内容稳定性，不因时间的改变而改变；相反，动态秩序的内容是可变的，只是它通过一套程序规范

〔8〕 参见刘金国、舒国滢主编：《法理学教科书》，中国政法大学出版社 1999 年版，第 249 页。

〔9〕 参见［波兰］列昂·彼得拉日茨基：《法律与道德》，于柏华译，商务印书馆 2023 年版，第 407 页。

〔10〕 关于应然状况，参见 Walter Anderssen, Die Bestandteile der Rechtsordnung, 20 Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie 569, 570 (1927)。关于应然语句，参见 Karl Engisch, Die Einheit der Rechtsordnung, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1987, S. 6。

〔11〕 参见［奥］汉斯·凯尔森：《纯粹法学说》，［德］马蒂亚斯·耶施泰特编，雷磊译，法律出版社 2021 年版，第 242 页以下。

中国知网 https://www.cnki.net

规定着自身规范的创制、变更与消亡，从而呈现出穿越时间之轴的连续性和可预测性。法秩序的统一性是创制性关联的统一性。法的独特性在于，它调整着自身的创制与适用。[12] 这意味着，既有法秩序只能按照自身固有的规则来续造和发展，缺乏这种法律创设的要素，法秩序就将静止。总之，法秩序的统一性并非固定的、内容意义上的静态统一性，而是在时间之流中以自我授权和限制为基础的兼具可变性和安定性的动态统一性。

（二）法秩序的构成

法秩序的基本组成单位是规范，法秩序首先是一个规范体系。此规范体系并非本体论意义上的存在者，而是基于实在法的法学构造物，更多是认识论的产物。因此，“法秩序的构成”并非指法秩序自身由哪些要素组成，而是指法学上构造法秩序时所择取的要素及其结构。

法秩序构成问题的核心是法秩序与法律体系之间的关系。对此，大体可区分出三种立场：一是同一论，即将法秩序完全等同于法律体系。这一立场将法律体系视为调整人类行为之一般规范与个别规范的总和。[13] 这里所谓个别规范包括司法判决、行政决定、民事法律行为等。这是一种相当独特的理解，因为在通常的语言用法中，“法”（法律体系）需具有“一般性”的特征，并不包含上述个别规范。[14] 用中国法学的话语来说，法只包括规范性法律文件，不包括非规范性法律文件。二是相异论，即认为法秩序与法律体系是两个不同且不相关的概念。法律体系是通过法教义学运用“私法和公法”“一般法和特别法”“实体法和程序法”等先验概念，对特定国家一切现行有效实在法予以重新阐释而形成的统一体（法律部门统一体），而特定国家的法秩序是该国家的一切实在法按各自的效力等级形成的层级统一体。[15] 但是，法律部门（及其背后的部门法价值）与效力等级其实只是依据不同标准对同一法律体系的划分而已。当代法理论普遍认可法律体系之外部体系与内部体系的划分，[16] 而这两者分别对应于法律规则之间根据效力关系形成的层级统一体，以及法律原则之间根据内容关系形成的价值统一体。三是包含论，其认为法秩序包含但不限于法律体系，前者相比于后者是一个在外延上更为宽泛的概念。

本文赞同包含论的立场。具体而言，法秩序由三个部分构成。首先，法秩序的主体部分无疑是法律体系。这里将“法律体系”理解为一般法律规范（制定法）的体系，它同时包括了外部体系（“规则—效力”体系）和内部体系（“原则—价值”体系）。重要的是，在外部体系的层面，除了效力等级的链条外，法律规则之间还具有其他关系。一个规则集合体要被称作“秩序”，就既要包括指向特定规范受众的规则，也要包括指向这些规则的规则。正是这后一类规则，调整着前一类规则的创制与适用。后一类规则又至少包括组织规则和程序规则两类。弗兰德贝格就认为，法秩序由法律规则体系和法律组织组成。法律组织具有六种典型功能，即法律创造功能、冲突解决功能、规则违反之处理功能、执行功能、审查功能和当事人援助功能。[17] 要发挥这六种典型功能，就需要设立相应的法律程序。所以，对于法秩序的参与者而言，法秩序

〔12〕 Vgl. Hans Kelsen, Der Begriff der Rechtsordnung, 3 Logique Et Analyse 154, 155, 158 (1958).

〔13〕 同上文，第 150 页。

〔14〕 例如，拉德布鲁赫对法的定义是，“人类共同生活的一般规定的总和”。Vgl. Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, 2. Aufl., hrsg. v. Ralf Dreier und Stanley L. Paulson, Heidelberg: C. H. Müller, 2003, S. 38.

〔15〕 参见王夏昊：《法律体系概念的反思和重构》，《江海学刊》2023 年第 6 期，第 151 页。

〔16〕 参见［德］卡尔·拉伦茨：《法学方法论》，黄家镇译，商务印书馆 2020 年版，第 548 页以下。

〔17〕 See Åke Frändberg, *The Legal Order: Studies in the Foundations of Juridical Thinking*, Switzerland: Springer, 2018, p. 64.

中国知网 https://www.cnki.net

不只是结果意义下的规范体系，还是一个程序的体系。[18] 但是，无论法律组织还是法律程序，都是由同一法律体系中的规则来确定的，本身也都具有法律规则的属性。一方面，法律创设和适用当然需要预设创设和适用法律之机关的存在，但什么机关在什么条件下有权进行法律创设和适用，本身也是由法律体系自身来确定的。[19] 因为法律组织拥有义务性、一般性的法律地位，而后者源自同一法律体系中的规则，与规范具有相同的本体论性质。[20] 换言之，法律组织必须获得法律授权，即拥有法律权能。另一方面，法律组织创设和适用法律的行为要能够产生特定的法律效果，必须符合程序法定的要求。特定机关如何进行有效的法律创设和适用，同样是由法律体系本身来规定的，程序规则也具有法律规则的属性。由此，可以将法律体系中的法律规则分为指向行动者的实体规范与指向实体规范的“权能—程序”规范。根据实体规范指向的行动者是一般民众还是法律适用者，又可以区分出行为规范（民法、行政法等）和裁判规范（侵权法、刑法等），后者提供了前者被违反或其所保护的法益受到侵害时的处理办法。在此意义上，行为规范、裁判规范和“权能—程序”规范就构成了逻辑上依次递进的统一体。[21]

其次，法秩序还包括得到制定法认可的其他一般规范。在当代中国，制定法是唯一的法的效力渊源，具有效力上的自足性。其他所有的一般规范，如果想要在法律适用活动中发挥裁判依据的功能，必须得到制定法（制度性权威）的直接或间接的认可。获得这种认可的一般规范就具有法的认知渊源的地位。[22] 否则，它们就只能在法律适用活动中发挥裁判理由的作用。法的认知渊源并不具备独立的效力来源，何种类型的一般规范是否可以作为，以及在多大范围内作为裁判依据，都需要依据法的效力渊源来作判断。例如，我国民法典第 10 条规定：“处理民事纠纷，应当依照法律；法律没有规定的，可以适用习惯，但是不得违背公序良俗。”这意味着，法官在处理民事纠纷时，如果制定法无明文规定，去寻找习惯规范来解决纠纷，同样符合“依法裁判”的要求。但是，此时裁判的约束力并不来自习惯本身，而是来自民法典第 10 条这一制定法条款。与此同时，法官亦有义务针对待适用的习惯规范进行审查（不得违背公序良俗）。据此，在当代中国，除了习惯外，国际条约、外国法、司法解释、指导性案例、国家政策，以及合宪性审查活动中的党的政策和党内领导法规等，都可能成为法的认知渊源。基于这些渊源的一般规范并不是“法”，也不属于本国“法律体系”的组成部分，但它们可以基于制定法的认可而对法律的运行和适用发挥重要的规范作用，因而同样属于本国法秩序的组成部分。可见，制定法外的一般规范能有条件地成为法秩序的组成部分。特定国家的法秩序是一个以本国制定法为主体的多元规范体系。[23]

最后，除了一般规范，法秩序也包括依据一般规范产生的个别规范。在逻辑学上，规范体

---

〔18〕 参见［德］罗伯特·阿列克西：《法概念与法效力》，王鹏翔译，商务印书馆 2015 年版，第 24 页。

〔19〕 Vgl. Martin Borowski, Die Lehre vom Stufenbau des Rechts nach Adolf Julius Merkl, in: Stanley L. Paulson und Michael Stolleis (Hrsg.), Hans Kelsen- Staatsrechtslehrer und Rechtstheoretiker des 20. Jahrhunderts, Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, S. 149.

〔20〕 参见前引〔17〕，Frändberg 书，第 62 页。

〔21〕 罗斯分别称之为“第一性规范”“第二性规范”“第三性规范”。See Alf Ross, *On Law and Justice*, Jakob v. H. Holtermann eds., trans., Uta Bindreiter, Oxford: Oxford University Press, 2019, pp. 251-253. 唯须注意的是，罗斯所称的“程序规范”是宽泛意义上的，包括了本文所说的“组织规范”。

〔22〕 法的效力渊源与认知渊源的区分，参见雷磊：《重构“法的渊源”范畴》，《中国社会科学》2021 年第 6 期，第 156 页以下。

〔23〕 规范体系的概念，参见刘作翔：《当代中国的规范体系：理论与制度结构》，《中国社会科学》2019 年第 7 期，第 85 页以下。

中国知网 https://www.cnki.net

系由规范集合及其规范后承（即某些将案件与解决办法联系在一起的规范语句）组成，规范集合与规范后承之间存在演绎性关联。[24] 这些规范后承在性质上属于个别规范。在法秩序中，虽然将一般规范与事实相结合得出个别规范的过程并非纯粹的理性认知过程，而难免有意志行为的作用空间，但无论在语义内容关系还是效力关系上，个别规范都是一般规范的逻辑后承。基于体系完备性的要求，法秩序既应包括一般规范，尤其是制定法和行政法规的抽象应然语句，也应包括具体的司法判决、行政决定和民事法律行为等。[25] 也就是说，虽然司法判决、行政决定和民事法律行为等个别规范不能被归入“法”或“法律体系”的范畴，但它们同样属于“法秩序”的组成部分，构成了法秩序之阶层构造的下层。这意味着，法秩序的统一性不仅涉及一般法律规范之间（诸类型制定法之间）的协调、一般法律规范与得到制定法认可的其他一般规范之间（如法律与习惯之间）的协调，也涉及这两类一般规范与个别规范之间（如法律与司法判决、习惯与司法判决之间）的协调，以及个别规范之间（如不同司法判决之间）的协调。

综上，法秩序是基于实在法的法学构造物，它预设了应然的和动态的视角。法秩序包括但不限于法律体系。它是以制定法为主体的多元规范体系，既包括一般法律规范（它们组成法律体系），也包括得到制定法认可的其他一般规范，以及依据一般规范产生的个别规范。

二、法秩序统一性的认识论要求

既然法秩序是基于实在法的法学构造物，那么“法秩序的统一性”就不外乎是法学方法的特定调整性理念，[26] 或者说是方法上的辅助概念。这意味着，法秩序的统一性并非对象或本体意义上的存在论统一，而是法律科学意义上的认识论统一。它既要求法律呈现出“秩序”，即一种可以被理性把握的“内在”的一致性，也要求该秩序具备“统一性”，即必须能被回溯到少数最高位阶的规范或支撑性的基本原则。[27] 这种统一性可以分为两个方面，一是法秩序的效力统一性，二是法秩序的价值统一性。如果说效力统一性是法秩序的纵向统一模式，那么价值统一性就是法秩序的横向统一模式。无论哪种统一模式，作为动态秩序之法秩序的统一性都体现在空间和时间两个面向上。

（一）法秩序的效力统一性

1. 空间面向：阶层构造与效力统合

法秩序的效力统一性在空间面向上既体现为法秩序的阶层构造，也体现为诸法源的效力统合。在理论上，如果一批规范构成统一体，它们就是一个秩序；如果它们具有同一个效力基础，它们就构成了统一体。[28] 因此，秩序的统一性首先就体现为效力统一性。法秩序之效力统一性的独特性体现在，同一秩序中的不同规范之间并非基于内容上的一般与特殊关系，而是基于上位与下位的授权关系（授权适用上位规范并创制下位规范）而传递其效力。对于归属

〔24〕 See Carlos E. Alchourrón & Eugenio Bulygin, *Normative Systems*, Wien and New York: Springer Verlag, 1971, p. 54.
〔25〕 参见前引〔10〕，Engisch 书，第 9 页。
〔26〕 同上书，第 3 页。
〔27〕 参见前引〔6〕，卡纳里斯书，第 5 页。
〔28〕 参见前引〔12〕，Kelsen 文，第 150 页。

中国知网 https://www.cnki.net

于阶层构造的某个规范而言，起决定作用的不是其内容，而是其效力基础。[29] 法秩序的统一性就体现为同一法秩序中所有规范都共享最终效力基础。这种确保统一性的最终“授权—效力”基础，在实在法体系内部就是宪法，而在法律逻辑的意义上则是基础规范。法秩序不同于道德秩序的一个重要特征在于，其所包含之规范的主要功能是规定创设下位规范的主体与程序。处于不同阶层且具有创设与被创设关系的规则，具有上位阶与下位阶的空间关系，由此形成法秩序的阶层构造。形象地说，法秩序呈现出“阶梯式人工瀑布”的图景。[30]

在法秩序的阶层构造中，从上位规范到下位规范、从一般规范到个别规范的阶层递进过程，就是规范的个别化和具体化过程。个别化是针对规范的调整对象而言的，具体化则是针对不同阶层之规范的抽象或具体程度而言的。较高阶层的规范针对更加一般的对象，而较低阶层的规范针对更加个别的对象。层层递进的过程也就是从适用一般规范创设不那么一般的规范，最终达致不可再个别化之阶层的过程。这一过程是从抽象规范到具体规范的逐步过渡。[31] 规范的个别化与具体化绝非纯逻辑推衍意义上的机械自动化过程。法律创制活动在其授权范围内被保留了一定法律创制的自由空间。下位规范的内容绝非完全被上位规范所包含，而总是留有具体化的自由空间，[32] 下位规范的创制者始终有自由裁量（立法裁量、行政裁量、司法裁量）的余地。就此而言，法律创设是一个动态的过程，其中发挥作用的既有客观要素，也有主观要素。客观要素是上位规范所确定的框架，它由两部分组成：一是“组织—程序”规范，它们确定了创制规范的构成要件，即下位规范的创制机关以及创制程序。这也是法秩序之动态性最主要的载体。二是特定的实体（内容）规范。法秩序虽然是动态秩序，但并不意味着其不可以规定实体内容。上位规范同样可以此方式来预先确定未来创制的下位规范的内容，即规定或排除掉某些内容，尤其是后者。[33] 这方面最典型的例子就是宪法基本权利条款。基本权利条款可以约束立法、行政和司法，也就意味着相关机关在依据宪法创制一般规范与个别规范时，不得与基本权利条款相矛盾。相反，主观要素是法律创制者在上位规范框架内运用自由裁量权时选择的内容。于此，获得授权的不同创制者可能依据同一上位法创制出内容不同甚至相冲突的下位规范，但它们都可能属于法秩序的组成部分。

在阶层构造中，法秩序的统一性意味着：一方面，下位法与上位法不相冲突。这又包括两个要求：一是下位法律规范不违反上位的组织和程序规范，二是下位法律规范不抵触上位的实体（内容）规范，[34] 除非上位法授权下位法这么做。例如，我国宪法第 34 条赋予年满 18 周岁的中国公民选举权和被选举权，但同时规定“依照法律被剥夺政治权利的人除外”。这其实相当于授权制定法在特定条件下剥夺年满 18 周岁的特定中国公民选举权和被选举权。但是，无论如何，这种剥夺性规定的效力基础依然在于宪法本身，作为下位法的剥夺性规定并不违反宪法的组织和程序规范。另一方面，下位法可以保持一定的开放性和相互的不一致性，只要它们始终在上位法所授权或允许的框架内即可。

以上所描述的法秩序的阶层构造主要适用于一般法律规范（制定法规范）和个别规范组

〔29〕 Vgl. Oliver Lepsius, Normenhierarchie und Stufenbau der Rechtsordnung, JuS 2018, S. 952.

〔30〕 Vgl. Theo Öhlinger, Der Stufenbau der Rechtsordnung, Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhanglung, 1975, S. 10.

〔31〕 Vgl. Adolf Merkl, Die Lehre von der Rechtskraft, Leipzig und Wien: Franz Deuticke, 1923, S. 221.

〔32〕 参见前引〔29〕，Lepsius 文，第 953 页。

〔33〕 尤其当上位规范是宪法时。参见前引〔11〕，凯尔森书，第 281 页。

〔34〕 抵触的具体情形，参见俞祺：《论与上位法相抵触》，《法学家》2021 年第 5 期，第 57 页以下。

中国知网 https://www.cnki.net

成的体系。但是，法秩序还包括得到制定法认可的其他一般规范。这些具备法的认知渊源地位的一般规范与认可它们的制定法共享效力基础。因此，法秩序的统一性也体现为一国内部诸法源的效力统合。在现代社会中，尤其是在法典化时代，法秩序虽然在内容层面上维系了“多元主义”的格局，但在效力层面上终结了“诸‘法’自立”的状况，使得制定法尤其是法典成为所有其他规范的效力来源，从而形成一种“诸‘法’归宗”的局面。[35] 关键在于，这些其他一般规范（如习惯规范）如何融入法秩序的阶层构造之中。必须看到，习惯规范并不像制定法规范那般彼此间存在授权与被授权关系，[36] 因而也不存在上位和下位的效力等级。作为认知渊源，习惯可以基于特定制定法规范或司法判决的认可成为法秩序的组成部分，而特定制定法规范或司法判决在阶层构造中又处于特定的阶层，因而习惯规范的效力层级与赋予其效力之规范的效力层级是一致的。这就使得习惯规范以“效力吸附”的方式进入法秩序的阶层构造之中。为了直观起见，可将统合了认知渊源（以习惯为例）的法秩序阶层构造示图如下：[37]

宪法（得到宪法认可的宪法惯例）

↓

法律（得到法律认可的习惯）

↓

行政法规（得到行政法规认可的习惯）

↓

规章、地方性法规（得到规章或地方性法规认可的习惯）

↓

……

↓

个别规范[司法判决、行政决定、民事法律行为等]（得到个别规范认可的习惯）

在上图中，居于顶层的宪法规范是独立规范，所有其余的规范都是依赖规范，因为它们直接或间接地依赖或衍生于宪法规范。居于各层级的习惯规范因得到相应法律规范的认可而被赋予制定法律的权威，因而也属于依赖规范。[38]

2. 时间面向：法的连续性与稳定性

在时间面向上，法秩序的效力统一性并不意味着现存法的效力是永恒不变的，而意味着法的效力具有连续性与稳定性。法秩序既然以实在法为基础，其所包含之规范自然有其产生、变更和消亡的过程。但是，这种变并不是完全任意和偶然的。只要特定法秩序的基础规范和根本

〔35〕 参见雷磊：《法典化的三重视角》，《法制与社会发展》2023 年第 2 期，第 67 页。

〔36〕 Vgl. Jorge A. Bacqué, Stufenbau der Rechtsordnung oder Einebnung der Normenpyramide?, in: Eugenio Bulygin und Ernesto Garzón Valdés (Hrsg.), Argentinische Rechtstheorie und Rechtsphilosophie heute, Berlin: Duncker & Humblot, 1987, S. 115.

〔37〕 需要说明的是：（1）为了简化问题，这里仅涉及实在法（不涉及基础规范），且就法的认知渊源而言仅涉及习惯。（2）是否存在与各层级的制定法或个别规范相对应的各类习惯，端视特定国家法秩序中各层级的制定法或个别规范创制行为是否认可它们。对此，不同法秩序不尽相同，因而该问题属于事实问题。（3）法秩序究竟具有多少层级同样因特定法秩序的不同而有不同，亦属于事实问题。（4）个别规范（如司法裁判）对习惯规范的认可属于个别认可，与制定法的一般认可不同，被个别规范认可的习惯规范在某种意义上亦具有个别规范的性质。

〔38〕 独立规范与依赖规范的划分，参见 Riccardo Guastini, *Legal System*, in Luka Burazin, Kenneth Einar Himma and Giorgio Pino (eds.), *Jurisprudence in the Mirror: The Common Law World Meets the Civil Law World*, Oxford: Oxford University Press, 2024, p. 204。

中国知网 https://www.cnki.net

宪法规范（宪制）不变，法秩序阶层构造各层级中规范的变迁就不影响整体法秩序在时间面向上的统一性。从根本上说，这依然是因为法调整着自身的创制和适用，是一个法律运行形成闭合网络的自治系统。[39] 这意味着，在时间面向上，法通过授权（组织和程序）关系规定着自己的产生、变更和消亡，从而呈现出跨时限的连续性与稳定性。法的连续性指的是某种事实在法律调整上的时间无缝隙性，也即是说，对于某种受到法律调整的事实而言，其不能在任何一个时刻点处于无法律调整的状态（否则将出现法律漏洞）。规范的变迁需要确保在旧规范与新规范之间不存在调整时间上的断裂，而要保证无缝对接。法的稳定性则意味着，无论法自身还是法的适用都要保持一定的稳定性，不应发生不可预测的突变。尤其是对于已经发生的事实，必须在时间上对应于发生当时有效的法，从而在理想情形中，每一个受到法律调整的事实，在特定时刻点上都应对应于特定的法，而不应处于法律状态未定的处境。进而，无论连续性还是稳定性，都致力于实现法的安定性和形式正义（一般性）的价值。

法秩序用以维系自身安定性的重要工具是法不溯及既往原则。法的效力在时间维度上总是向后延展的，它不可能在事实上去拘束已经发生了的事件或行为。法是否能溯及既往问题的本质，是它能否对于已经发生的事件或行为进行回溯性评价，从而对事件或行为的当事人在未来产生影响。法不溯及既往原则否认了这种回溯性评价的可能性，从而使得新法生效以前的事件和行为，通常只能适用当时有效的旧法。这种对回溯性评价的原则性禁止，既适用于个别规范的创制（司法和执法行为），也适用于一般规范的创制（立法行为），因此属于宪法层面的原则。在宪法层面，法不溯及既往构成法治国家原则的子原则，旨在限制法律创制权在时间效力维度的形成自由，以保护公民对现行法的主观信赖。[40] 由此，通过对法律关系形成与法律生效的时间点比较，来对对应于特定法律关系之法律的效力时段进行分配，法秩序既保障了每个特定时刻点所形成之法律关系都有规范基础，也确保了这种规范基础不会在下一个时刻点发生不可预测的变更。当然，有时法律关系并非形成于某个时刻点，而是发生于新旧法律交替时，此时新旧法的效力关系就相对复杂，需要针对不同的法律关系领域进行不同的教义学作业。[41] 此外，如果公民对于旧法的信赖不再值得保护，则新法将被允许溯及既往。这就遭遇了法不溯及既往原则的适用界限，也遭遇了法的安定性价值的界限。但是，无论如何，法秩序统一性原理要求以不溯及既往（从旧）为原则，以溯及既往（从新）为例外。

综上，法秩序的效力统一性是一种动态统一性，不仅体现为空间面向上不同规范间的阶层构造，也体现为时间面向上规范的连续性和稳定性。法秩序不仅规定了自我创制和适用的空间，也通过区分和连接各个应然时间来规制时间，以至于它为行为创造了时间，也限制了时间。[42]

（二）法秩序的价值统一性

1. 空间面向：部门法间的价值协调

法秩序的价值统一性首先体现为部门法间的价值协调。[43] 与效力不同，价值并不具有等级性，不同部门法及其背后的价值并无高下之别，它们之间无法像效力那样被层层回溯至一个

〔39〕 参见［德］贡塔·托依布纳：《法律：一个自创生系统》，张骐译，北京大学出版社 2004 年版，第 9 页。

〔40〕 参见姜秉曦：《法不溯及既往的宪法意涵及其界限》，《清华法学》2024 年第 1 期，第 172 页。

〔41〕 参见贺栩栩：《法的时间效力界限与法的稳定性——以德国民法为研究视角》，《环球法律评论》2011 年第 5 期，第 65 页以下。

〔42〕 See Hans Lindahl, *Boundaries and the Concept of Legal Order*, 2 Jurisprudence 81 (2011).

〔43〕 换个角度说，法秩序价值统一性的任务就是解决同一法秩序内不同部门法要素因悖反评价协调性要求而产生的实体冲突。参见吴冬兴：《法秩序统一性导向下部门法冲突的司法调适》，《法律科学》2025 年第 1 期，第 46 页。

中国知网 https://www.cnki.net

终极的、最高的价值原则。同时，不同部门法之间的价值是有差异的，这种差异来自部门法性质与任务的不同。因此，法秩序的价值统一性是不同部门法及其不同价值之间的协调统一，而非完全的同一。这意味着，部门法间的价值协调以部门法之间的差异为出发点，统一的法秩序不是从某个预设的先验价值出发进行推衍并分化为不同部门法的产物，而是由不同价值及其支持的诸部门法进行协调统合的产物。

部门法间的价值协调体现在两个方面：其一，不同部门法之间需要相互配合和协力以实现各自的价值，这尤其体现在程序法部门与实体法部门之间的关系上。正如恩吉施所言，离开民事诉讼法所开启的追诉和执行的可能性，（民法所保护的）主观私权利就是“无刃之剑”，甚至就不是主观权利。〔44〕反过来说，如果离开了对侵害主观权利之行为的追诉和对侵害赔偿的执行，民事诉讼法就是空转的。其二，不同部门法需要在承认各自价值差异的基础上实现特定意义上的价值统合。〔45〕部门法的划分虽然具有时代性和实用主义的考量，但从根本上说，在理想法秩序中，每个成熟的部门法都具有不同的性质，各自是一个相对自治的系统。具体而言，首先，不同部门法的目的不同。例如，民事救济的目的是实现矫正正义，而刑事惩罚的目的是实现报应正义。矫正正义的本旨在于恢复受害者的权利，而报应正义的本旨在于施加罪犯所应得的恶害。〔46〕其次，不同部门法责任的性质不同。民事侵权责任、行政责任和刑事责任分别对应三种不同类型的伦理义务，违反这三类伦理义务将产生三种不同的违法性。承担民事侵权责任的前提是侵犯民事权利，即违反个人间的私人义务（私人不法）；承担行政责任的前提是违反特定的行政管理规范，行为人成为了社会合作中的“搭便车者”，违反了社会合作参与者的公平合作义务（合作者不法）；而承担刑事责任的前提是挑战了政治共同体的基本共享价值，违反了政治共同体成员的公民基本义务（公民不法）。〔47〕但是，承认部门法自治并不否认部门法之间的价值联系和相互协调的可能，更不支持部门法的绝对分离。尤其是，当下方兴未艾的法典化运动在强化部门法内部统一性的同时，也更为鲜明地将部门间价值协调的必要性置于了前台。

不同部门法之间的价值协调十分复杂，往往交织着历史的、政治的和教义学的考量。在法理论的层面上仅能指明两点：其一，法秩序或多或少由相同的法律思想和一般原则所支配。它们作为共同的价值基点在创设具体法律规定内容时要得以维系，尽管这并非没有例外，且在不同法领域中具有不同的具体化形态。〔48〕这些相同的法律思想和一般原则，往往表现为法秩序所要遵从的抽象法理念。例如，法的安定性与正义这两个法理念，以及正义理念内部的两种类型，即形式正义（一般正义）与实质正义（个别正义）之间的辩证关系，在不同的部门法领域中就可能展现为不同原则。〔49〕要再次强调的是，作为法理念的具体化，不同部门法中的不同原则并不是从相同的法理念出发进行纯粹逻辑推衍的产物，而只是说，不同部门法的价值原

〔44〕 参见前引〔10〕，Engisch 书，第 34 页。

〔45〕 如果说法秩序的效力统一性在宪法和行政法领域体现得较为明显的话，那么民法和刑法领域更关注的则是法秩序在价值统合意义上的统一性。这也是为什么不同部门法学者在谈法秩序统一性时，所预设的法秩序模式（阶层构造模式或部门法体系模式）并不相同的原因。

〔46〕 See Arthur Ripstein, *Force and Freedom: Kant's Legal and Political Philosophy*, Boston: Harvard University Press, 2009, pp. 86-106.

〔47〕 参见前引〔1〕，张峰铭文，第 177 页以下。

〔48〕 参见前引〔10〕，Engisch 书，第 35 页。

〔49〕 参见［德］卡尔·拉伦茨：《正确法：法伦理学基础》，雷磊译，法律出版社 2022 年版，第 24 页以下。

中国知网 https://www.cnki.net

则可以回溯到相同的法理念对自身予以证成，因而可能具有统一的“价值基点”。

其二，法秩序虽然不为行为提供统一的禁止性理由，却应提供统一的正当化理由。统一的违法性概念首先只是形式性的。由于部门法性质存在差异，不同法律部门的违法性之间毫无疑问存在实质差异。那么，私法与公法相统一意义上的法秩序统一性又意味着什么？答案是，它要求始终根据评价和衡量所有相关利益之后的整体法秩序，以及根据对制定法中呈现的一切秩序和价值基点的平衡来确认行为的违法性，使得法律义务的证立与不法的排除具有普遍效果。〔50〕这体现在，法秩序的不同部分之间存在着允许性判断（法律上可为之事）上的一致性和禁止性判断（法律上禁为之事）上的差异性。只有当一个行为具备某一部门法固有的违法性，且不能被任何整体法秩序内部的正当化理由所正当化时，才能说某行为具备部门法违法性。相反，在判断一个行为在某一部门法内是否具备合法性时，只需考虑其是否违反了本部门法的禁止性理由，而无需考虑其是否违反其他部门法的禁止性理由。部门法违法性判断需要考虑整体法秩序内部的全体正当化理由，但部门法合法性判断却不需要考虑整体法秩序内部的全体禁止性理由。正当化理由可以在各部门法之间自由流通，但禁止性理由则保持相对隔离状态。〔51〕这是因为，一切法律上的正当化理由本质上都是实践理性的要求，而人的实践理性是统一的（当然，同一正当化理由在不同部门法中可能具备不同强度）。〔52〕因此，在违法性判断或者说行为理由的意义上，法秩序的统一性是一种（仅着眼于正当化理由）片面的统一性，法秩序的价值统合也是一种片面的而非全面的统合。

2. 时间面向：同案同判

法秩序的价值统一性不仅体现在空间面向上，也体现在时间面向上。时间面向的价值统一性要求，对于不同时间点上的事实状态或法律关系，法秩序应给予大体相同的评价。这尤其体现在不同时间点所形成的个别规范之间的关系上，以同案同判原则为典型。简单地说，同案同判就是要求类似案件类似处理。如果两个案件在法律上相同或相似，那么就有理由处以相同的法律后果。〔53〕“同案”指的是同类案件或类似案件，判断已决案件（前案）与待决案件（后案）是否属于同案的关键，是判断两者是否具有相关相似性，而这无疑涉及法律上的评价。“同判”并不要求同案的结果完全一致，而只是主张：如果前案与后案属于同案，那么对两者作出相同裁判就具备了初步理由。在司法裁判过程中，法律规则及其背后的正当化依据、法律体系内的法律原则和所有其他相关规则，都必须被识别并衡量。案件的结论必须建立在对各理由之重要程度的通盘考量之上。如果出于个案正义的考虑，需要在后案中偏离前案（个别规范）的判决，那就可以作出差异化判决。在此，同样将遭遇法秩序之统一性的界限。但是，无论均质化判决还是差异化判决都会涉及价值判断。所以，同案同判不只是一个逻辑关系原则，还是一个时间关系原则。它要求将前案（个别规范）所确立的价值判断跨越时间之流通过后案得到保持和贯彻。由此，法秩序的价值稳定性就得以维系。

与法不溯及既往一样，同案同判也是法秩序维系自身安定性的方式。它在个案层面实现了法的可预期性的显现化。面对“同案”，法官的判决越具统一性，法律对行为的指引在客观效

〔50〕 参见前引〔10〕，Engisch 书，第 58 页。

〔51〕 参见张峰铭：《论“一般违法性”的法理定位与教义学功能——以部门法判断协调问题为中心》，《环球法律评论》2023 年第 2 期，第 84 页。

〔52〕 See John Gardner, *Offences and Defences: Selected Essays in the Philosophy of Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press, 2007, pp. 91-120.

〔53〕 参见雷磊：《如何理解“同案同判”？——误解及其澄清》，《政法论丛》2020 年第 5 期，第 34 页。

中国知网 https://www.cnki.net

果上就越确定，公众就越清楚法律的具体要求为何。从系统论的观点看，同案同判其实是作为裁判组织的“记忆”和“预期”结构在个案裁判中发挥作用。它意味着，在法律系统内部以之前/之后区分为基础的认知图示中，对已发生的“前案”的记忆和对尚未发生的未来“后案”的预期，作为决策条件而对当前个案裁判形成的影响和制约。[54] 在此，“之前”和“之后”的区分不只是客观时间上的区分，而更多是法律体系之内在时间上的区分。由此，法秩序之价值统一性的时间面向也就获得了一种超越客观时间的含义，彰显了法的可预期性这个统一的价值基点。

与法的连续性和稳定性不同，同案同判之所以被视为法秩序之价值统一性而非效力统一性在时间面向上的要求，是因为除了在遵循先例的英美法系国家外，在其他国家，包括在我国，同案同判都不具备法律拘束力，也非裁判者的法律义务。尽管我国近年来连续推出的案例指导制度和类案检索制度均以“统一法律适用”为目标，但无论指导性案例、各类典型案例，还是参考性案例，都不具有法律效力。同案同判在我国仅是裁判者要追求的司法道德义务，是法秩序之价值统一性的具体要求。

（三）效力统一与价值统一的耦合

在特定法秩序中，无论以阶层构造模式为依托的效力统一，还是以部门法模式为基础的价值统一，最终都将在宪法位阶上实现耦合。宪法既是最高法，也是根本法。作为最高法，宪法在实在法体系内构成了法秩序之效力的最高顶点，任何法律、行政法规、规章和个别规范都不得与宪法相冲突。同时，法律规范所追求的目的是多样化且相互竞合的，受制于历史的和社会文化的变迁。法秩序的价值规划最终根植于政治的和世界观的确信。作为根本法，宪法提供了法秩序统一的价值判断基准，要求在其他部门法中直接或间接地落实这些基本价值安排，或至少部门法价值不能与这些基本价值相悖。职是之故，基本权利的第三人效力理论，只有在法秩序统一性思想的背景下才能被完全理解。[55] 统一法秩序虽然不是由某些至上目的自上而下派生的产物，却是各个自治领域经由宪法统合的产物。各部门法虽然有各自独立的目的，但都受制于宪法性价值，尤其是基本权利条款。对于规范目的的理解要时刻以合宪为依归，这本身就是法秩序统一性的体现。[56]

总之，宪法规范既是法秩序中其他规范的最终效力判准，也是其他规范的价值基础。当然，这不否认法律创制者在创制其他下位阶规范时拥有“形成空间”，而是说，宪法必须对部门法的立法进行约束和审查。这种约束和审查的制度化，就是现代国家所建立的合宪性审查制度。统一性的概念就产生于一种合乎宪法的和谐化解释，故而是法院和法律适用者的产物。[57] 与西方国家的司法审查不同，我国建立起了以全国人大及其常委会为主体，包括“前端”（法律草案审议中的审查）与“后端”（备案审查）在内的合宪性审查体制。[58] 但是，无论何种审查模式，都以“内容形成”和“越界控制”的方式来发挥宪法的约束作用。前者意味着，立法者必须考量宪法在相关领域设定了何种国家目标，要求达到何种基本权利保障标准；后者意味着，在考量该法律部门规范领域的特定情形而形成具体规范时，立法者不能逾越宪法设定

〔54〕 参见泮伟江：《论同案同判拘束力的性质》，《法学》2021 年第 12 期，第 23 页。

〔55〕 参见前引〔6〕，卡纳里斯书，第 65 页。

〔56〕 参见前引〔1〕，张峰铭文，第 178 页。

〔57〕 Vgl. Bernd Rüthers, Christian Fischer und Axel Birk, Rechtstheorie mit Juristischer Methodenlehre, 8. Aufl., München: C. H. Beck, 2015, S. 96.

〔58〕 参见张翔：《“合宪性审查时代”的宪法学：基础与前瞻》，《环球法律评论》2019 年第 2 期，第 14 页。

中国知网 https://www.cnki.net

的边界，不能背弃国家目标，不能侵害基本权利。[59] 因此，合宪性审查既是一种效力审查，又是一种价值审查，从而成为法秩序之效力统一和价值统一的耦合机制。可见，追求法秩序之统一性的时代，也必然是合宪性审查的时代。

三、法秩序统一性的方法论构造

法秩序的统一性不仅提出了认识论要求，也必然要依循这些要求进行具体的方法论构造。在司法裁判中强调法秩序统一性原则，本质上就是主张裁判者应尽可能在考量整体法秩序的基础上进行法律适用。[60] 在此，法秩序统一性原则与法教义学处于双重逻辑关系之中，即同时作为法学作业的公理和假设。[61] 当法秩序的统一性被有意地或隐蔽地假定存在，并被作为法律思考的基础时，这一原则就作为公理起作用。而当法秩序的统一性一开始被忽视，只是通过法学作业才重新得以确立时，这一原则就作为假设起作用。前一种情形包括借助同一法秩序的其他部分来补充法律规范，以及运用体系性关联来理解法律规范的含义（规范意义的体系化塑造）；后一种情形包括对同一法秩序中各类规范冲突的解决（规范要求的一致化建构），以及对各类规范漏洞的填补（规范体系的完备化发展）。

（一）规范意义的体系化塑造

诚如施塔姆勒所言，适用单个法条，最终是适用整个法秩序。[62] 这意味着，特定法律规范需要从整体法秩序的其他部分获得补充要素，或借此阐明其用语的准确内涵，以实现规范意义的体系化塑造。

1. 规范补充

在法秩序中，每个（语法意义上的）法条都不仅对同一部制定法中的其余部分保持开放，而且也可能对法秩序的其余部分保持开放。[63] 这包括三种情形：其一，制定法规范通过同一制定法或同一部门法中的其他规范来补充。这主要涉及不完全法条的情形。不完全法条并不具备构成要件或法律后果，而是对完全法条起到说明、限制作用或提示援引其他法条、将某事拟制为特定概念的法条。[64] 据此，又可区分出三种子情形：（1）通过限制性法条的补充。限制性法条是指排除特定案件类型，以限制其他法条适用范围的法条。当特定法条的文义范围太广，以致涵盖了原本不应适用其法律后果的案件时，可以通过限制性法条予以限定。例如，我国民法典第 188 条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为 3 年；法律另有规定的，依照其规定。海商法第 257 条规定，就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为 1 年。显然，海商法第 257 条即属于“法律另有规定”的情形，构成对民法典第 188 条第 1 款的限制。（2）通过引用性法条的补充。引用性法条是构成要件或法律后果参引其他法条才能确定的法条。例如，民法典第 647 条规定，当事人约定易货交易，转移标的物的所有权的，参照适用买卖合同的有关规定。这意味着，易货交易与一般的交易（以钱易货）事实上

〔59〕 参见张翔：《宪法与部门法的三重关系》，《中国法律评论》2019 年第 1 期，第 28 页。

〔60〕 参见前引〔5〕，吴冬兴文，第 26 页。

〔61〕 参见前引〔10〕，Engisch 书，第 69 页。

〔62〕 Vgl. Rudolf Stammler, Theorie der Rechtswissenschaft, 2. Aufl., Halle: Buchhandlung des Waisenhauses, 1923, S. 15.

〔63〕 参见前引〔10〕，Engisch 书，第 27 页。

〔64〕 参见黄茂荣：《法学方法与现代民法》，厦门大学出版社 2024 年版，第 156 页以下。运用说明性法条对完全法条进行补充，在本文中被归类为“体系解释”，下文将作专门说明。

中国知网 https://www.cnki.net

并不一样，但立法者认为“转移标的物的所有权的”情形于两者而言差别不大，所以要参照适用民法典买卖合同的相关规范。（3）通过拟制性法条的补充。拟制是立法者明知案件类型T1与案件类型T2是不同的构成要件，为赋予它们相同的法律效果，而将两者视为等同。例如，民法典第18条第2款规定，16周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。这其实是将年满16周岁且以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人（劳动成年者）拟制为年满18周岁的成年人（完全民事行为能力人），从而将后者的法律后果在整体上赋予前者。

其二，制定法规范通过其他部门法规范来补充。这具体包括两种类型：（1）通过特定构成要件的吸纳来补充。法律规范的构成要件既可以明文援引其他部门法规范，也可以默示援引其他部门法规范对本规范予以补充。刑法上所谓“行政犯”或“法定犯”就是典型。一个行为是否成立行政犯，要经过行政从属性和刑事不法判断独立性的二重筛选。〔65〕在此，违反行政法规是法定犯构成要件的规范要素，行政法规是法定犯的前置法，只有违反行政法规的行为，才有可能构成犯罪。〔66〕其中，明文援引的例子如，我国刑法第286条之一将“网络服务提供者不履行法律、行政法规规定的信息网络安全管理义务”，规定为“拒不履行信息网络安全管理义务罪”的构成要件之一；默示援引的例子如，刑法第336条将“未取得医生执业资格的人非法行医”，规定为非法行医罪的构成要件之一。此处关于“未取得医生执业资格”的判断，显然需要依据执业医师法以及相关法规的规定来进行。（2）通过引用性法条来补充。例如，民法典第502条规定，依法成立的合同，自成立时生效；依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。这一条文要求适用者直接去参看法律、行政法规是否有关于特定合同需经批准、登记而生效的规定，如有则从其规定，从而不适用“自成立起生效”的规定。与通过同一制定法或同一部门法的拟制性法条进行的补充有所不同，通过其他部门法的引用性条文进行的补充是纯粹对构成要件或法律后果的参引，而不涉及两种情形的类似性判断。

其三，制定法规范或制定法外的其他规范通过法的认知渊源来补充。这也包括两种类型：（1）通过认知渊源补充制定法规范。例如，《最高人民法院关于审理涉彩礼纠纷案件适用法律若干问题的规定》（法释〔2024〕1号）第6条规定，双方未办理结婚登记但已共同生活，是否返还彩礼以及返还的具体比例，应根据彩礼实际使用及嫁妆情况，综合考虑共同生活及孕育情况、双方过错等事实，并结合当地习俗来确定。这是对长久以来存在的民间习惯的认可，其实质是对民法典总则部分规定的公平原则（第6条）以及婚姻家庭编一般规定部分规定的“禁止借婚姻索取财物”原则（第1042条第1款）的具体化。（2）通过认知渊源补充制定法外的其他规范。例如，民法典第510条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。在此情形中，交易习惯就可成为补充合同相关内容的来源。

2. 体系解释

统一、无矛盾、内部一致的法秩序概念被应用于各种论证场合，特别是有争议的法律解释的场合，〔67〕其中最典型的是运用体系解释方法的场合。体系解释又称为“基于关联的解释”，是指将被解释的法律规范放在整部制定法乃至整个法秩序之中，联系此规范与其他规范的相互

〔65〕 参见马春晓：《法秩序统一性原理与行政犯的不法判断》，《华东政法大学学报》2022年第2期，第43页。

〔66〕 参见陈兴良：《法定犯的性质和界定》，《中外法学》2020年第6期，第1464页。

〔67〕 Vgl. Alexander Hanebeck, Die Einheit der Rechtsordnung als Anforderung an den Gesetzgeber, 41 Der Staat 429 (2002).

中国知网 https://www.cnki.net

关系来解释法律规范的含义。据此，体系解释既要求避免采取会和其他法律规定相矛盾的解释（连贯性要求），又要尽量采取和其他法律规定在价值上相容乃至相互支持的解释（融贯性要求）。〔68〕依循法秩序统一性原理进行的体系解释可分为如下三种情形。

其一，联系同一制定法中的其他规定来解释特定法律规范。这包括三种情形：（1）基于关联来解释构成要件。最典型的情形是联系一部法典的总则条款来解释分则条款。例如，刑法第 400 条规定，司法工作人员私放在押的犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯的，处 5 年以下有期徒刑或者拘役。至于“司法工作人员”的认定范围有多大，需联系刑法总则第 94 条关于“本法所称司法工作人员”的规定予以解释。（2）基于关联来（补充）解释法律后果。例如，民法典第 577 条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。什么样的行为算作“继续履行”，什么样的行为算作“采取补救措施”，都需联系民法典第 579 条和第 582 条的规定来作补充解释。（3）通过位置对比来解释法律规范。立法者根据章、节、条、款、项、目的顺序来编排法条是有整体性考虑的，特定法律规范在制定法中的位置安排往往有助于理解其含义。例如，民法典第 1247 条规定了“饲养危险动物致人损害”的侵权责任，但没有明确责任类型。如果查看侵权责任编的安排就可发现，这个条款被规定在第 9 章“饲养动物损害责任”中，与第 1 章“一般规定”相对，而一般规定以过错责任为原则，以法律特别加以规定的无过错责任为例外。据此可知，饲养危险动物致人损害要承担无过错责任。

其二，联系同一法律体系中的其他规定来解释特定法律规范。基于部门法的自治性，不同部门法对同一用语的解释可能是不同的。例如，民法与刑法关于“近亲属”的认定范围就有所不同，对于“死亡”的理解（是否包含“宣告死亡”）亦有不同。但是，宪法作为根本法和最高法的地位决定了，裁判者在对其他部门法条款进行解释时，不能违反宪法的明文规定，且要符合宪法的基本价值安排，这就要求对普通法规范进行合宪性解释。合宪性解释的基本原则植根于法秩序整体性的原则之上：为了保证法秩序的整体性，所有根据宪法制定出的法律，都必须与宪法协调一致地被加以解释。〔69〕如果存在两种可选择的法律解释，而法官没有选择那种更符合宪法价值的解释，就将违背其维护法秩序统一性的义务。例如，刑法所保护之法益的内核应被认为是宪法上的基本权利。在对刑法第 290 条第 3 款规定的“扰乱国家机关工作秩序罪”进行适用时，要联系宪法第 35 条和第 41 条关于公民相关基本权利的规定，以及第 27 条第 2 款关于国家机关“为人民服务”的规定，作限缩解释。〔70〕

其三，依据制定法外的其他一般规范来解释特定法律规范。法的认知渊源不仅可以充当特定法律规范的构成要素，也可以对特定法律规范的用语进行解释。典型情形之一是通过司法解释条款来解释制定法用语。例如，刑法第 336 条关于非法行医罪的规定以“情节严重”为构成要件之一，而最高人民法院《关于审理非法行医刑事案件具体应用法律若干问题的解释》就对此规定了“情节严重”的五种情形。典型情形之二是通过习惯规范来解释制定法用语。例如，德国民法典第 157 条规定，对合同的解释，应遵守诚实信用原则，并考虑交易惯例。再如，我国民法典第 726 条规定，出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。至于何谓“合理期限”，可以参考案件发生地

〔68〕 参见雷磊：《法理学》，中国政法大学出版社 2021 年版，第 177 页。

〔69〕 参见［德］康拉德·黑塞：《联邦德国宪法纲要》，李辉译，商务印书馆 2007 年版，第 56 页。

〔70〕 参见张翔：《刑法体系的合宪性调控——以“李斯特鸿沟”为视角》，《法学研究》2016 年第 4 期，第 55 页。

中国知网 https://www.cnki.net

的普遍交易惯例来确定。

（二）规范要求的一致化建构

法秩序统一性的一个重要议题是解决法秩序内部各种类型的规范冲突，以实现同一秩序之规范要求的一致化建构。在此意义上，甚至有学者将法秩序统一性原则直接等同于法秩序无矛盾性原则。[71] 规范冲突的起因是法秩序的动态性，但这也成为了法学作业及其成果的催化剂。[72] 学理上可以从不同的角度对规范冲突进行分类，并相应提出不同的解决办法。根据法秩序的构成，本文将法秩序内部的规范冲突分为三种情形。

一是法律体系内部的规范冲突。当代方法论的主流观点将法律规范区分为法律规则与法律原则。法律规则是一种确定性命令，具有明确的构成要件和法律后果；而法律原则是一种最佳化命令，具有“分量”的向度，能够在不同情形中不同程度地被实现。[73] 这事实上也对应于外部体系与内部体系的区分：外部体系是规则体系，属于法律体系的刚性部分；而内部体系是原则体系（价值体系），属于法律体系的柔性部分。由此，法律体系内部的规范冲突可以分为三种子类型：（1）法律规则之间的冲突。这种冲突既可能发生在抽象的效力层面，也可能发生在具体适用的层面。[74] 在效力冲突的情形中，一个抽象的行为看起来同时是被要求的和不被要求的，或者是被禁止的和不被禁止的，或者完全是被要求的和被禁止的。[75] 效力冲突通常可以依据预设的第三方准则来解决，如“上位法优于下位法”“新法优于旧法”“特别法优于一般法”。其中“上位法优于下位法”的准则优先于其他两个准则，也即只要两个法律规则具有位阶上的高低，就无需再考虑时间关系和逻辑关系。这是由法秩序的阶层构造决定的。当发生冲突的两个法律规则处于同一位阶，其中一个既是新法又是一般法，另一个既是旧法又是特别法时，就需作实质判断。我国立法法第 105 条只针对法律和行政法规作了程序性规定，即同位阶法律规则对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由制定机关（全国人大常委会或国务院）裁决。在适用冲突的情形中，两个法律规则本身在表述上并不冲突，但当它们同时适用于同一个具体行为时发生了冲突性竞合。这一行为在同一法秩序中可能同时被要求和被允许，或者既被判断为合法也被判断为违法。它们之间往往不存在位阶、时间和逻辑关系，此时只能回溯至法律规则背后的法律原则，对它们进行个案权衡。（2）法律原则之间的冲突。法律原则之间的冲突发生在具体适用的层面，只能权衡相冲突之原则在个案中的分量来决定优先适用何者。在此，必须遵循衡量法则，即对某一原则的干预越强，另一个原则实现的重要性就应当越高，[76] 进而需要依据重力公式展开具体的权衡论证。[77]（3）法律规则与法律原则的冲突。一个法律规则的背后同时得到两类原则的支持，即实质原则和形式原则。形式原则没有内容，指向的是法的安定性，提出的是“立法者的意志应当得到遵从”的要求。当法律规则与法律原则发生冲突时，要同时将法律原则与法律规则背后的

〔71〕 参见前引〔5〕，吴冬兴文，第 24 页。

〔72〕 参见前引〔10〕，Engisch 书，第 67 页。

〔73〕 参见［德］罗伯特·阿列克西：《法、理性、商谈：法哲学研究》，朱光、雷磊译，中国法制出版社 2011 年版，第 177 页以下。

〔74〕 参见前引〔10〕，Engisch 书，第 46 页。

〔75〕 参见［德］卡尔·恩吉施：《法律思维导论》，郑永流译，法律出版社 2004 年版，第 200 页。

〔76〕 参见［德］罗伯特·阿列克西：《法律原则的结构》，雷磊译，载胡建淼主编：《公法研究》第 7 辑，浙江大学出版社 2009 年版，第 472 页。

〔77〕 关于重力公式，参见［德］罗伯特·阿列克西：《法：作为理性的制度化》，雷磊编译，中国法制出版社 2012 年版，第 148 页以下。

中国知网 https://www.cnki.net

实质原则和形式原则相权衡。换言之，若想在个案中优先适用原则，不仅要确立此原则相对于规则背后赋予其正当性之彼原则的优先性，而且必须证明：为何此原则的重要性是如此之高，以至于可以偏离权威机关透过规则所作出的决定。[78]

二是制定法规范与法律体系外其他规范的冲突。这可以分为两种情形：（1）法律规则与其他规范的冲突。来自法的效力渊源（制定法）的法律规则无疑在效力上优先于其他规范，但在适用上则既可能优先于其他规范，也可能次后于其他规范。法律规则在效力和适用上均优先于其他规范的情形，如民法典第 10 条关于“处理民事纠纷，应当依照法律；法律没有规定的，可以适用习惯”的规定。法律规则在效力上优先、在适用上却次后于其他规范的情形，如民法典第 480 条规定，承诺应当以通知的方式作出；但是，根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外。据此，在要约的承诺方式上，基于交易习惯的“行为”在适用上要优先于法律规则本身规定的“通知”。再如，民法典第 204 条规定，期间的计算方法依照本法的规定，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。据此，在期间的计算方法上，当事人的约定（民事法律行为）要优先于“本法规定”适用。但是，即便在这类情形中，法律规则在效力上依然优先于这些其他规范（习惯或约定），正是制定法规则本身给予了这些其他规范优先于自身适用的地位。（2）法律原则与其他规范的冲突。这类冲突的解决较为复杂，无法一言以蔽之。仍以民法典第 10 条为例：通常认为，该条所说的“法律”仅包括法律规则，而不包括法律原则。原因在于，法律原则的适用并不受表达其法条之文义的限制，故而适用范围十分宽泛，如将习惯置于原则之后，难免有架空习惯之虞，从而导致民法典在漏洞情形中通过习惯来拘束法官裁量权之意旨落空。所以，在民事纠纷中，习惯次后于法律规则但优先于法律原则得以适用。[79] 不过，该条后半句又施加了适用习惯“不得违背公序良俗”的限制。“良俗”包括作为事实上确定状态的“风俗”和作为附加的价值评判的“善良”两部分。很显然，“风俗”就是共同体成员交往实践中形成的习惯，善良的习惯也是习惯，理解公序良俗首先要以习惯的事实存在为基础。所以，看起来公序良俗原则绝对优先于习惯适用，但其实在该原则具体化的过程中同样要运用到习惯。同时，“善良”的基本评判是要符合法秩序中的宪法价值安排。可见，优先关系决定的背后，既涉及特定习惯所体现的价值与公序良俗原则之间的权衡，也涉及合宪性判断。

三是法律体系外其他规范之间的冲突。这种冲突主要是适用层面的冲突，既可能发生在一般规范之间（如国家政策与习惯），也可能发生在个别规范之间（如司法判决与民事法律行为），还可能发生在一般规范与个别规范之间（如习惯与民事法律行为）。解决来自不同认知渊源之规范间的冲突，要同时考察它们与制定法的关联、权威性程度和实质内容等诸多因素，这些往往须依据个案而定，并适时进行教义学上的类型化总结，不可一概而论。这里仅提出四条一般性准则：（1）原则上应依据相关联的制定法的位阶性判断优先关系。认知渊源需要得到制定法规范的认可，而制定法规范具有位阶性。通常而言，在同一事项上，被上位法认可的认知渊源要优先于被下位法认可的认知渊源得到适用。例如，党的政策因为宪法第 1 条第 2 款的间接认可而成为宪法层面的法源。[80] 如果在民事裁判领域中，党的政策与民法典认可的习惯发生冲突，则党的政策原则上优先适用。（2）原则上制度性权威优先于非制度性权威。法

〔78〕 Vgl. Robert Alexy, Theorie der Grundrechte, Frankfurt a. M. : Suhrkamp Verlag, 1994, S. 89.

〔79〕 参见于飞：《民法总则法源条款的缺失与补充》，《法学研究》2018 年第 1 期，第 36 页以下。

〔80〕 参见雷磊：《“宪法渊源”意味着什么？——基于法理论的思考》，《法学评论》2021 年第 4 期，第 45 页。

中国知网 https://www.cnki.net

的渊源在性质上属于权威理由，而权威既可以基于制度，也可以不基于制度。当法律的存在条件是某种法律制度发挥作用，而法律的与语境完全相适的证立或者其规范力仅来自于这些存在条件的满足时，它就拥有一种严格制度化的渊源。[81] 例如，司法解释、指导性案例、国家政策都属于基于我国现行法律制度产生的制度性权威，而习惯、民事法律行为是基于民众的普遍规范性实践或当事人的个别规范性实践产生的非制度性权威。当两者发生冲突时，前者原则上优先于后者适用，除非制定法作出相反规定。（3）在民事裁判领域中，民事法律行为优先于其他非制度性权威。这是因为民法领域奉行意思自治原则，当事人的意思表示或合意优先于习惯等因袭性规范。（4）应当选择最符合宪法价值安排的优先关系。合宪性判断是所有冲突解决方案最后的审查步骤，在前续步骤中得出的冲突解决办法需要经受合宪性控制。这是法秩序统一性的最终保障。

（三）规范体系的完备化发展

法秩序统一性原理不仅追求法秩序内部的一致性（无矛盾和融贯性），也追求法秩序的完备性。规范体系的完备化发展要求尽可能地消除体系的“漏洞”，[82] 这又有赖于法秩序的“目的论特质”：[83] 法秩序的目的论统一是漏洞填补最重要的基础。从经验的意义上说，立法者所创制的法律体系（对象体系）不可能不存在漏洞，法秩序的完备性或无漏洞性是一种理想而非现实，但这同时也对法律科学提出了通过认知体系或理论来填补对象体系之漏洞的任务。简单地说，漏洞是“应规定而未规定”的状态。其中，“未规定”涉及经验确认，“应规定”则属于价值判断。漏洞不是简单的缺失状态，而必须是不合目的的，或者说依其目的被评价为不应存在的缺失状态。在此意义上，法律漏洞只可能发生在法律体系之外部体系（规则）的层面，而无法发生在内部体系（原则）的层面。因为原则本身就是法律体系的价值判断基础，其适用范围相对宽泛，且不受文义的限制。在规则层面上，广义的法律漏洞包括三种类型：一是要素漏洞，也即法律规则对相关问题进行了规范但并不完整，或者说法律规则的构成要件或法律后果存在要素欠缺；二是规定漏洞，是指需被规范的问题完全欠缺某一相关法律规则；三是规整漏洞，是指需被规范的问题在总体上欠缺法律调整，而此种调整需要借助一批法律规则（规整）来进行。[84] 但是，所谓要素漏洞涉及运用目的解释或前述法的认知渊源来补充制定法规范的情形，并不属于严格意义上的或狭义的漏洞。狭义的法律漏洞包括规定漏洞和规整漏洞两类情形，它们对应于不同的漏洞填补方法。

规定漏洞的填补包括两种途径：（1）基于相关法律规则之扩张适用的漏洞填补。[85] 当针对需被规范的案件类型 T1 缺乏明文的法律规则时，将同一法律体系中规范案件类型 T2 的法律

〔81〕 See Roger Shiner, *Strictly Institutionalized Sources of Law: Some Further Thoughts*, 20 Ratio Juris 311-312 (2007).

〔82〕 关于完备性及其与漏洞之关系的逻辑界定，参见前引〔24〕，Alchourrón 等书，第 20 页。

〔83〕 “如果法秩序具有目的论的特质、具有一定目的实现的手段的特质的话，那么法秩序的‘统一性’也就意味着目的论的统一性。”［日］京藤哲久：《法秩序的统一性与违法判断的相对性》，王释锋译，《苏州大学学报（法学版）》2020 年第 1 期，第 150 页。

〔84〕 卡纳里斯从漏洞的确定方法的角度，将这三类漏洞分别称为“目的性漏洞”“禁止拒绝裁判漏洞”“原则与价值漏洞”（参见［德］克劳斯-威廉·卡纳里斯：《法律漏洞的确定：法官在法律外续造法之前提与界限的方法论研究》，杨旭译，北京大学出版社 2023 年版，第 123 页）。但是，“原则与价值漏洞”的名称会令人误以为是原则或价值本身存在漏洞，故本文不采。

〔85〕 许多学者将“目的性限缩”也列为漏洞填补的方法（参见前引〔16〕，拉伦茨书，第 492 页）。这是因为他们将规定漏洞区分为明显的漏洞与隐蔽的漏洞，将目的性限缩作为填补隐蔽的漏洞的方法。但是，所谓隐蔽的漏洞其实涉及的是法律修正而非漏洞填补。

中国知网 https://www.cnki.net

规则 N 的法律后果扩张适用至 T1。如果扩张的依据是 T1 与 T2 之间具有法律上的相关相似性，则使用的方法为类推，此即“基于相似性的论证”。如果扩张适用的依据是 T1 与 T2 虽不相似却共享同一立法目的（N 背后的立法目的），则使用的方法为目的性扩张（“当然推理”属于其特殊情形），此即基于目的的论证。但是，类推与目的性扩张并无严格区分，两者只具有程度的差别。无论运用何种方法，关键都在于找到法律规则 N 背后的立法目的，所谓“相关相似性”的判断也正是在此一目的的关照下进行的。因此，填补规定漏洞时，方法论上的重要任务就在于确定隐藏在法律规则背后的目的并予以证成。（2）基于法的认知渊源的漏洞填补。规定漏洞也可以借助制定法之外的其他规范（如习惯）来进行填补。有疑问的是，当法无明文规定时，是优先适用习惯，还是优先类推适用相关法律规则。例如，当民法典第 10 条规定“法律没有规定的，可以适用习惯”时，此处的“法律”是否包括法律规则的扩张适用？这一问题在学理层面上涉及对“法律”的理解，其关键在于“法律”究竟仅是一种文义的体系，还是兼为文义和目的的体系；在实践层面则涉及特定国家对待习惯的政策性态度，即对国家的制度性意图（大传统）与社会自治（小传统）之间关系的协调。〔86〕在此并无一定之规，而需要结合不同法秩序的价值追求，针对不同适用场景作教义学上的归纳总结。

规整漏洞的填补也包括两种情形：（1）基于法律原则的创制性填补。针对某一需要规范的问题，出现法律规整（法律规则集合）总体性缺失的情形时，裁判者可以通过对一般法律原则（如缔约过失原则、诚实信用原则、善良风俗原则等）的具体化来填补漏洞。由于法律原则并不具备类似于法律规则的逻辑结构，无法直接将案件事实涵摄于其下，因而它“通常并不提供能够无疑义适用的规整，而只是指明寻找解决途径的方向，所以还需要另一个特殊的过程，从而将原则转化为法条”。〔87〕原则的这种具体化不同于解释，它会为裁判者留有更大的裁量空间，即价值取舍和手段选择意义上的创制空间。这意味着，不同裁判者完全可能基于相同的法律原则创制出填补漏洞的不同法律规则或规整。为了约束这种裁量权，一是在法律原则的具体化过程中应采纳案例对比法，通过各种论据证明同一原则所可能适用之相似案件之间的可比性；二要诉诸法律渊源或归纳来论证法律原则，并通过演绎或权衡来实现法律原则的具体化（“垂直”的具体化或“水平”的具体化）。〔88〕（2）基于法的认知渊源的创制性填补。裁判者也可以运用来自同一认知渊源的诸多规范，或者运用来自不同认知渊源的诸多规范来填补规整漏洞。有疑问的是：如果不同认知渊源的诸多规范发生适用冲突怎么办？如果来自认知渊源的规范与法律原则发生适用冲突怎么办？这两个问题分别涉及前述“法律体系外其他规范之间的冲突”和“法律原则与其他规范间的冲突”，需依前文提供的冲突解决思路来处理，而无论采取何种漏洞填补方式，均需经受合宪性审查。

结 语

法秩序的统一性既是法律科学追求的理想，又是司法裁判的辅助性原则。法秩序的统一性理想对应于特定的认识论要求，而法秩序的统一性原则要求进行特定的方法论构造。这种理想

〔86〕 参见雷磊：《“法的渊源”意味着什么?》，中国政法大学出版社 2021 年版，第 252 页。

〔87〕 前引〔84〕，卡纳里斯书，第 141 页。

〔88〕 参见［德］托马斯·M. J. 默勒斯：《法学方法论》，杜志浩译，北京大学出版社 2022 年版，第 432 页以下。

中国知网 https://www.cnki.net

或原则的“价值基点”在于法的安定性和形式正义的法理念。但是，法的安定性或形式正义不代表法的全部理念或价值。法的统一性仅仅要求评价形式的“一致性”，它通常只能对已经（至少初步地）存在的评价进行“穷尽思考”，并将其适用于类似的案例中，消除其与其他已经设定的评价的矛盾，并在设定新的评价时阻止矛盾出现，而不可能创造全新的评价，也无法确保实质上的正确性。〔89〕在逻辑上，并不排除符合法秩序之统一性的要求，但实质上仍然不正确之法律决定的存在。追求法秩序的统一性亦非没有代价。从共时性的角度来看，它最大的代价就是丧失法的多样化所带来的益处。法秩序的统一性不应导致对某些应保持适度开放之事实问题在法律上的“石化”，这些问题的解决依赖于不断变迁的社会和经济政策评价。〔90〕从历时性的角度看，法秩序统一性的代价可能是丧失法律后续发展的灵活性。法的统一性并非毫无疑问地等同于法律发展的进步，强制的统一性往往意味着保守性。〔91〕因此，法秩序的统一性或许值得追求，但它是法秩序必要而非充分的构成条件，是相对的而非绝对的理想原则。

Abstract: Legal order is a construction in legal science based on positive law that presupposes an ideal and a dynamic perspective. Legal order consists of legal system, other general norms recognized by statutory laws, and individual norms derived from general norms. Therefore, it is a multi-normative system with statutory laws as the main body. The unity of legal order is not only an ideal pursued by legal science but also the auxiliary principle of judicial decision. The epistemological requirements for the unity of legal order have two aspects. One is the unity of validity of legal order, including not only the hierarchical structure and validity integration of law in the spacial dimension, but also the continuity and stability of law in the temporal dimension. The other is the unity of values of legal order, including the value coordination between branch laws in the spacial dimension, and the principle that like cases being decided alike in the temporal dimension. These two aspects should be coupled together at the constitutional level. The methodological conformation for the unity of legal order is embodied in the systematic shaping of the meaning of legal norms, the consistent construction of normative requirements, and the complete development of the normative system. The “value basic point” of the unity of legal order lies in legal certainty and formal justice. It is a necessary but not sufficient constituent condition of legal order, and a relative rather than an absolute ideal principle.

Key Words: legal order, legal system, legal application, the principle that like cases being decided alike, unification of legal system

〔89〕 参见前引〔6〕，卡纳里斯书，第43页以下。

〔90〕 Vgl. Hein Kötz, Rechtsvereinheitlichung - Nutzen, Kosten, Methoden, Ziele, 50 Rabels Zeitschrift für ausländisches und Internationales Privatrecht 12 (1986).

〔91〕 Vgl. Peter Behrens, Voraussetzungen und Grenzen der Rechtsfortbildung durch Rechtsvereinheitlichung, 50 Rabels Zeitschrift für ausländisches und Internationales Privatrecht 31, 32 (1986).

中国知网 https://www.cnki.net